

1500228-46.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500228-46.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500228-46.2022.8.26.0545 Controle nº 317/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2052171/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23199167 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2052171 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 25/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

FERNANDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de fevereiro de 2022, às 23h30, na Rua Alfeu Vilaça, 260, Recanto Elizabeth, nesta

cidade e Comarca de Bragança Paulista, trazia consigo, para consumo de terceiros e fornecimento alheio, 18 (dezoito) papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 13g, 8 (oito) pedras de crack, pesando aproximadamente 2g e 32 (trinta e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 60g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente, acostados aos autos. Em 14.03.2022, a Acusação aditou a denúncia, de modo a constar que o acusado foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 97).

O acusado foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 105). A denúncia e o aditamento formulado foram recebidos em 19.05.2022 (fls. 108/110), sendo o acusado devidamente citado (fls. 131).

Durante a instrução, foi produzida a prova oral, através de audiência por videoconferência, com a oitiva de duas testemunhas comuns, sendo, ao final, o réu interrogado (fls. 132/133).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, ocasião em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a parcial procedência da ação, afastando-se apenas o aditamento formulado (artigo 40, III, da Lei 11.343/06), em razão do horário dos fatos. Por fim, teceu comentários em relação à dosimetria da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com base na negativa por ele apresentava no tocante à prática delitiva. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, no patamar de 1/2. Pugnou, ainda, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo auto de constatação preliminar (fls. 18/19), pelo laudo pericial (fls. 85/93), assim como pelos depoimentos colhidos.

A autoria delitiva também é certa.

Nas duas oportunidades em que ouvido a respeito dos fatos, o acusado alegou que, na data em questão, caminhava em posse de certa quantia em dinheiro, pois havia sido convidado por seu primo para comer um lanche. Em dado momento, um homem esbarrou em seu corpo, ocasião em que uma moeda de um real caiu ao solo. Abaixou-se para pegá-la e, nesse momento, visualizou a viatura e um policial vindo em sua direção. Em razão do temor que sentiu, decidiu empreender fuga. Foi, então, abordado e agredido pelos policiais, que a todo momento o questionavam a respeito da existência de drogas. Como não levava entorpecentes consigo, os agentes da lei afirmaram que forjariam seu encontro. Ressaltou que a sacola, cuja propriedade lhe é imputada, foi retirada do "porta-luvas" da viatura, por um dos policiais. Afirmou, por fim, não ter exposto tal situação na delegacia de polícia, uma vez que sentiu medo. O conjunto probatório existente nos autos, contudo, demonstra que o acusado incorreu no delito que lhe é imputado na peça acusatória.

O policial militar, Tiago Cardoso de Lima, explicou que se encontrava em deslocamento, próximo ao local dos fatos, quando avistou o acusado, pessoa que lhe era desconhecida. Notou que ele estava abaixado próximo a um mato, mexendo em uma sacola, em um conhecido ponto de tráfico de drogas da cidade. O réu, que inicialmente não havia notado a presença policial, no momento em que seu parceiro de farda desembarcou da viatura para aborda-lo, arremessou a sacola que manuseava e empreendeu fuga. Seu parceiro, então, pegou a sacola e retornou a viatura, a bordo da qual perseguiram o acusado, logrando êxito em abordá-lo mais a frente. Durante revista pessoal, foram localizados em seu poder dois aparelhos celulares. Todavia, ao verificarem o interior da sacola dispensada pelo réu, foi constatada a existência de 32 porções de maconha, 18 papelotes de cocaína e algumas porções de crack. Não se recorda a respeito do que o acusado disse na ocasião sobre os entorpecentes localizados.

No mesmo sentido, o policial militar, Marcelo Fagundes, explicou que efetuava patrulhamento em local próximo ao dos fatos, quando visualizou o acusado abaixado, em um conhecido ponto de tráfico de drogas. Aduziu que, a princípio, ele não havia notado a viatura, mas arremessou uma sacola ao solo e saiu em fuga quando constatou que seria abordado. Pegou a referida sacola e partiu em seu encalço, em um primeiro momento à pé, e, na sequência, à bordo da viatura, juntamente com seu colega de farda. Conseguiram, então, abordar o acusado um pouco a frente, ocasião em que, indagado a respeito das drogas armazenadas na sacola apreendida, ele preferiu não se manifestar a respeito. Em seu poder foram localizados apenas dois celulares. Ressaltou, por fim, não ter visualizado nenhum outro objeto no local de início da abordagem e, tampouco, outras pessoas ali presentes.

Pois bem. Consoante se extrai do conjunto probatório, há prova segura acerca da responsabilidade criminal do acusado, em que pese sua negativa.

Observe que os policiais ouvidos em juízo apresentaram um relato seguro e coeso, idêntico àquele prestado por eles em sede policial, esclarecendo a forma como os fatos se deram, com riqueza de detalhes.

Ambos foram uníssonos em descrever que visualizaram o réu dispensando uma sacola, em cujo interior constaram haver entorpecentes, no momento em que ele empreendeu fuga, logo após notar que seria abordado pela equipe.

Anoto aqui que as testemunhas, em razão da função pública que exercem, bem como do compromisso que prestaram em juízo de dizer a verdade, merecem total confiabilidade. Ademais, não há sequer indício mínimo nos autos de algum interesse dos agentes em incriminar, de forma injusta, o acusado, pessoa que lhes era desconhecida, não havendo motivos para deles duvidar ou para excluir seus depoimentos.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes”.

Ademais, o depoimento dos agentes da lei está em consonância com as demais provas coligidas aos autos, especialmente pela apreensão das drogas, que foi consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão, e pelo laudo químico-toxicológico, que confirmou se tratar de maconha e cocaína os entorpecentes apreendidos (fls. 85/93).

Diante de tal contexto, não se pode simplesmente ignorar as circunstâncias presentes no autos e que denotam a traficância, ante à negativa apresentada pelo acusado.

Verifico que sua versão, no sentido de que apenas procurava parte do dinheiro que levava para comer um lanche, e que teria caído ao solo, quando fora avistado pelo agentes da lei, ocasião em que não detinha consigo entorpecentes, carece de verossimilhança e restou isolada diante do conjunto probatório acostado aos autos. Inicialmente, observo que o acusado não demonstrou nos autos qualquer circunstância capaz de justificar uma falsa incriminação, praticada pelos agentes da lei contra si, não se desencumbindo do ônus que lhe competia, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ora, não é crível conceber que policiais militares, responsáveis por zelar pela segurança pública, andassem pela cidade, imputando a posse de drogas a pessoas inocentes, com o único intuito de incriminá-las, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração de motivação para tal comportamento.

Ademais, embora o réu sustente que se dirigia a uma lanchonete, a convite de seu primo, logo após ter deixado sua namorada, nenhuma dessas pessoas foi arrolada para comparecer em juízo e confirmar a versão apresentada, a qual restou destituída de qualquer comprovação.

E ainda, a fragilizar ainda mais a tese do réu, verifico que os policiais afirmaram em juízo que, nada, além da sacola dispensada pelo acusado, foi encontrado no local onde ele se encontrava abaixado, bem como que com ele foram localizados apenas dois celulares.

Denota-se, assim, que, não apenas inexistia dinheiro caído ao solo, situação que,

segundo o réu, o teria motivado a abaixar-se para procura-lo, como, ainda, que também não havia dinheiro em seu poder, contrariando sua tese de que fora abordado no momento em que se dirigia a uma lanchonete para comprar um lanche.

Mais a mais, sua pronta atitude de se evadir, ao notar a presença policial, não se coaduna àquela apresentada por alguém que ali estivesse de boa fé e bem evidência que ela decorreu da ciência acerca da ilicitude de sua conduta, uma vez que incorria no tráfico de drogas.

Resta, assim, imputar ao acusado a responsabilidade pelas drogas apreendidas nos autos.

A finalidade de mercancia, por sua vez, é extraída especialmente pelas circunstâncias do caso.

E aqui, em que pese o fato de não ter sido encontrada droga em quantidade elevada, observo não se tratar de quantia ínfima. Além disso, os entorpecentes apresentavam naturezas diversas (maconha, cocaína e crack), de modo a atender aos diversos públicos deste mercado ilícito, bem como se encontravam fracionados e embalados individualmente, prontos para a comercialização, conforme demonstra, inclusive, a fotografia de fls. 17 dos autos.

Cumprido ressaltar, ainda, que o acusado se encontrava em um conhecido ponto de tráfico de drogas da cidade, conforme relatado pelos policiais ouvidos, circunstância que, atrelada à atitude suspeita apresentada, justificou sua abordagem.

Ademais, consigno que a simples ação de portar os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Irrelevante, pois, se não há a efetiva prática do ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado mantendo em depósito ou guardando a substância entorpecente com finalidade de venda.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma, por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

Afasto, contudo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas. Isto porque, apesar de o laudo de fls. 82/84 apontar a existência de um Centro de Referência de Assistência Social nas proximidades do local da abordagem do acusado, os fatos se deram por volta das 23h30min, ou seja, em horário que, fatalmente, ninguém ali sequer permanecia. E aqui, oportuno consignar que a ratio legis da majorante em apreço diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais, em virtude da maior concentração de pessoas. Assim, não se pode admitir sua aplicação se a prática de narcotraficância ocorria em horário em que tal circunstância não se fazia presente, como na hipótese dos autos.

Ora, a proximidade do referido Centro de Assistência teria funcionado como elemento meramente circunstancial, sem relação real e efetiva com a traficância realizada.

Oportuno, aliás, citar o seguinte entendimento a respeito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018, que: "Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, se a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas."

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser imposta.

Partindo-se do mínimo legal de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, não vislumbro a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis e que exijam a fixação da pena acima do mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da menoridade relativa, mas que não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado. Isto porque o acusado é primário e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas ou que integre alguma organização criminosa. Mesmo porque, a prisão se deu por acaso, sem que houvesse denúncias de seu nome no tráfico de drogas. Ademais, ambos os policiais ouvidos afirmaram nunca tê-lo visto nas imediações, bem como que não o conheciam dos meios policiais. Assim, diante da razoável quantidade da droga apreendida e de seu potencial nocivo, uma vez que além das porções de maconha, havia 18 papéletes de cocaína, bem como 8 pedras de crack, reduzo a pena em 1/2, de modo que chego a 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, fixados estes no mínimo legal. O dia-multa será fixado no mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquelas genericamente mencionadas por ocasião de seu interrogatório, insuficientes para tanto. Ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos C. Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido: "EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida". (HC n.º 118.533, Rel. Cármen Lúcia, j. Em 23.06.2016)". Também deve-se consignar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, através do recente julgamento proferido nos autos do habeas corpus coletivo nº 596.603 (2020/0170612-1): "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE."

Sob essas premissas, cabe ao Julgador analisar a realidade dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

Portanto, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos C. Tribunais Superiores, frente às particularidades acima e com base no art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para a execução da pena privativa de liberdade, em seu início. Levo em consideração, ainda, consoante supramencionado, a quantidade de pena fixada, inferior a 4 anos, além da primariedade do réu. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena privativa, além do recolhimento domiciliar noturno (entre 22 horas e 5 horas).

Considerando-se as circunstâncias expostas e a pena a ser aplicada, ressalto que o

acusado poderá apelar em liberdade, tal qual já se encontra.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado FERNANDO APARECIDO DA SILVA ao cumprimento de uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, vigente na data dos fatos, por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em regime inicial aberto, com conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena privativa, além do recolhimento domiciliar noturno, com possibilidade de recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento dos aparelhos celulares apreendidos nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 22 de agosto de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA